

1501313-04.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Sette Carvalho

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... nem quando era adolescente; foi para essa vida de tráfico porque estava difícil de arrumar emprego; não é usuário de drogas.

A testemunha Cristiano Ramos de Oliveira, policial civil, disse que na época dos fatos, receberam denúncia anônima informando que no bairro Paraíso do Tanque estava ocorrendo tráfico de drogas e que os indivíduos que estavam traficando usavam de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501313-04.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501313-04.2021.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS VASCONCELOS MAGRI e outro

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Sette Carvalho

LUCAS VASCONCELOS MAGRI e BRUNO DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 02 de dezembro de 2021, por volta das 17h30min, na Rua José Wilson de Carvalho, 300, Paraíso do Tanque, em Atibaia, agindo em concurso e unidade de desígnios, traziam consigo, para fins de tráfico ilícito, drogas, consistentes em 19 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, 59 porções de crack e 16 porções de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nos termos da denúncia, na data da ocorrência, policiais civis e guardas municipais receberam uma denúncia dando conta de que no local dos fatos estaria ocorrendo tráfico de drogas, sendo que os responsáveis pelo comércio ilícito contavam com a ajuda de "olheiros" e se utilizavam de rádios "HTs".

Conforme constou da exordial, a fim de averiguar a informação, a equipe deslocou-se até lá em viaturas descaracterizadas, ocasião em que avistaram os ora réus, os quais estavam na posse de rádios comunicadores. LUCAS ainda trazia consigo uma pochete na cintura.

De acordo com a inicial, após breve campana, os agentes públicos presenciaram LUCAS se aproximar de outro indivíduo, posteriormente identificado como Kaue de Andrade Barbosa, aparente comprador, razão pela qual decidiram abordá-los, assim, como ao

réu BRUNO.

A preambular narrou que após revista pessoal, foram encontrados em poder de BRUNO vinte e três porções de crack. O réu LUCAS, por seu turno, portava dezesseis porções de cocaína, trinta e seis porções de crack e dezenove porções de maconha, além de R\$ 4,00. Já com Kaue, foi localizada uma porção de crack e, indagado, ele confirmou ter adquirido o entorpecente de LUCAS, horas antes.

O flagrante do réu LUCAS foi convertido em prisão preventiva, enquanto para BRUNO, a prisão em flagrante foi convertida em liberdade provisória mediante cumprimento de condições (fls. 59/66). A denúncia foi oferecida (fls. 100/102) e os réus foram notificados (LUCAS às fls. 140 e BRUNO às fls. 170). Ambos apresentaram defesas preliminares (LUCAS às fls. 147 e BRUNO às fls. 179/182), que foram afastadas, tendo havido o recebimento da denúncia (fls. 184/187). Os réus foram citados (BRUNO a fls. 223 e LUCAS a fls. 226). Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas, sendo os réus interrogados ao final (fls. 248/249 e 273/274).

Em memoriais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia (fls. 278/283).

A defesa de LUCAS requereu, em síntese, a absolvição do réu, por insuficiência de provas, argumentando que as provas formadas não foram suficientes para a condenação. Invocou, desta forma, o princípio in dubio pro reo. Para o caso de condenação, requereu fosse reconhecida a confissão espontânea como forma de atenuar a pena a ser aplicada. Postulou, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa de BRUNO, por sua vez, postulou a absolvição do réu e, para o caso de condenação, o reconhecimento da atenuante relativa à confissão, bem como a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, uma vez que o réu não contava com 21 anos à época dos fatos. Requereu, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Passo a decidir.

A ação penal é procedente.

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), no boletim de ocorrência (fls. 03/06), no auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 23/24), nas fotografias dos entorpecentes (fls. 42/47 e 88/89), no laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 110/112) e na prova oral produzida.

A autoria criminosa deve ser imputada aos réus.

LUCAS, interrogado extrajudicialmente (fls. 13), disse que na data da ocorrência estava numa viela que fica na Rua José Wilson de Carvalho, sendo que estava em poder de uma pochete com porções de crack, maconha e cocaína; também estava em poder de um rádio "HT"; em dado momento, percebeu a aproximação de um rapaz que reside ali no bairro, sendo que já havia vendido uma porção de crack para ele anteriormente; conversou com tal rapaz por poucos segundos; logo em seguida prosseguiu caminhando pelas imediações da viela, momento em que foi abordado por policiais civis que estavam num automóvel Fiat/Palio; não percebeu a presença dos policiais; no momento da abordagem, estava com sua pochete contendo as porções de entorpecente e seu rádio "HT"; todo o entorpecente encontrado consigo era destinado a venda.

BRUNO, por sua vez, interrogado extrajudicialmente (fls. 14), disse que não vende entorpecente, explicando que trabalha apenas como "campana" e avisa aos meninos que estão vendendo droga; fica posicionado num ponto do Bairro Paraíso do Tanque, de onde consegue avistar a entrada de veículos no bairro; tem a obrigação de avisar os meninos que estão vendendo entorpecente para que eles não sejam surpreendidos quando da chegada de uma viatura policial e também de movimentação suspeita; estava com uma pequena porção de crack; ganha o valor de R\$ 50,00 por dia trabalhando de "campana"; não sabe o nome da pessoa para quem trabalha e não sabe o nome da pessoa que o paga; no momento da abordagem da polícia, estava com um rádio, o qual usava para avisar os meninos que estavam vendendo droga.

Em juízo, o réu LUCAS confessou o delito; assumiu que estava praticando o tráfico de drogas, mas disse que diversas coisas que falaram não são verdadeiras; no dia dos fatos, carregava consigo uma pochete na qual havia doze porções de maconha,

quinze porções de cocaína e catorze porções de crack; foi abordado junto com o usuário, para quem tinha acabado de efetuar a venda de uma porção de crack; tinha também uma quantia em dinheiro, no valor de R\$ 50,00 e não com R\$ 4,00 como disseram; tinha também um rádio comunicador, pelo qual mantinha contato com BRUNO, que era apenas o "olheiro"; não tinha motivo de estar com todas aquelas drogas que disseram que tinha; no dia dos fatos, foi abordado pela viatura descaracterizada, ocasião em que assumiu a prática de tráfico de drogas; falou também que a pessoa que estava junto realmente era um usuário que tinha acabado de adquirir consigo uma porção de crack; foi algemado e colocado no banco de trás da viatura descaracterizada; logo em seguida, chegou a viatura da ROMU e um policial, cuja aparência não se recorda, saiu de tal viatura e veio em sua direção; já estava algemado, no banco de trás da viatura descaracterizada; o policial pediu para o outro agente abrir a porta de trás do carro, sendo que desferiu diversos socos em sua cabeça, um soco no seu queixo e um soco em sua barriga, aplicando em sua pessoa, ainda, um mata-leão; ficou quase sem ar nenhum, mas não chegou a desmaiar; nesse momento, um policial à paisana pediu para que o outro agente parasse; tal agente disse que sua pessoa era um menino bom, que confessou os fatos e não tentou correr; BRUNO não esteve na mesma abordagem que sua pessoa e Cauê em momento nenhum; indagado sobre constar um exame no qual não é apontada nenhuma lesão, respondeu que não tem lesões, mas foi o que aconteceu; indagado sobre levar socos na cara e não constar lesões, respondeu que não foi na cara, mas sim na cabeça, em seu queixo e na barriga; traficava no local havia aproximadamente uma semana, ou alguns dias mais; tinha vinte anos quando foi preso; não tem outras passagens; estudou até o primeiro ano; às reperguntas da acusação, respondeu que BRUNO era apenas "olheiro"; tinha um rádio comunicador para avisar se a polícia chegasse; quando chegou para traficar, BRUNO já era "olheiro".

BRUNO, judicialmente, disse que estava na campana, era "olheiro" de LUCAS; avisava LUCAS caso houvesse polícia chegando; já estava nessa atividade com LUCAS há mais de um mês; sempre trabalhou com LUCAS nessa função; quando LUCAS chegou, já estava trabalhando como "olheiro"; fazia cinco meses que estava trabalhando como "olheiro"; desses cinco meses como "olheiro", um foi junto com LUCAS; encontraram crack consigo, sendo que estava com 43 pedras de crack; o restante da droga foi encontrado com LUCAS; além de "olheiro", também ficava com parte da droga; trabalhava de "olheiro" e de "meio" também, que é quem ajuda o traficante a vender; estudou até o primeiro colegial; tem 21 anos; não tem nenhuma passagem pela polícia, nem quando era adolescente; foi para essa vida de tráfico porque estava difícil de arrumar emprego; não é usuário de drogas.

A testemunha Cristiano Ramos de Oliveira, policial civil, disse que na época dos fatos, receberam denúncia anônima informando que no bairro Paraíso do Tanque estava ocorrendo tráfico de drogas e que os indivíduos que estavam traficando usavam de "olheiros" para que fossem avisados sobre a chegada da polícia, bem como rádio HT para comunicação; em diligência juntamente com a guarda municipal, utilizando viaturas descaracterizadas, dividiram-se em equipes; avistaram o réu LUCAS numa viela, subindo, sendo que quando outro indivíduo se aproximou dele, supostamente para efetuar uma compra, efetuaram a abordagem de ambos; LUCAS trazia consigo uma pochete e um rádio HT em suas mãos; na pochete havia 16 porções de cocaína, além de crack e maconha, bem como R\$ 4,00 em dinheiro; em abordagem, o réu afirmou que já havia vendido para o usuário que ali estava, chamado Kauê, horas antes; o réu confessou que estava efetuando o tráfico naquele local; participou da abordagem tão somente do réu LUCAS; outra equipe abordou o réu BRUNO, da qual não participou, mas soube que foi localizado com tal indivíduo um rádio HT e uma quantidade de crack; não soube dizer se BRUNO confessou a traficância; indagado se o crack encontrado com BRUNO estava embalado da mesma forma do crack encontrado com LUCAS, respondeu não se recordar.

A testemunha Marcela Abrantes de Aguiar, policial civil, disse que o Setor de Investigações recebeu denúncia dando conta de que no bairro do Tanque estava ocorrendo tráfico de entorpecentes numa viela; foram até o local em viaturas descaracterizadas, uma vez que a denúncia dava conta de que havia muitos "olheiros"; dividiram-se em duas equipes; foi com a equipe do Dr. Hermes efetuar

campana, em distância aproximada de duas ruas acima da viela; durante a campana, observaram que o réu possuía rádio HT e se comunicava com outra pessoa a todo tempo, bem como andava de um lugar para outro; em determinado momento, decidiram abordar o réu; com ele, encontraram porções de crack, além de um rádio; as porções de crack estavam embaladas de formas distintas e prontas para a venda; naquele momento, o réu confessou a traficância; tratava-se do réu BRUNO; o outro réu foi abordado pela outra equipe; BRUNO confessou que aquelas drogas eram destinadas ao tráfico mesmo; não se recordou sobre o que BRUNO disse em relação ao tempo que praticava a traficância; não soube dizer se o entorpecente que estava com BRUNO estava embalado de forma idêntica ao entorpecente que estava com LUCAS; às reperguntas da acusação, indagada se em volta do local dos fatos havia algum lugar com alta concentração de pessoas, respondeu que pelo que se recorda, o local era uma rua e tinha duas vielas, mas não se recorda de escola ou de nenhum local com alta concentração de pessoas.

A testemunha Luís Henrique Cometti Leme, guarda municipal, disse que em uma ação em conjunto com a Polícia Civil pelo bairro Jardim Paraíso do Tanque, havia várias denúncias de tráfico de entorpecentes numa viela, bem como que as pessoas que ali traficavam se comunicavam via rádio HT; foi informado de que toda vez que chegava uma viatura caracterizada, os indivíduos conseguiam se esconder e nunca eram vistos; foi montada uma campana pelos agentes da Polícia Civil; os agentes da campana ficaram em lugares secretos; sua viatura ficou em outro local estratégico, observando uma determinada rua; diante dos fatos e dos relatos da Polícia Civil, um adolescente, usuário, chegou até LUCAS para comprar entorpecentes, momento em que ocorreu a abordagem; LUCAS trazia consigo uma pochete e várias porções de drogas embaladas separadamente para o comércio; dentre as drogas, havia cocaína, crack e maconha; na rua em que estava, permaneceram observando outro indivíduo, BRUNO, que também estava com HT; o tempo todo ele se comunicava com alguém, que supostamente seria LUCAS; assim que a Polícia Civil iniciou a ação, abordaram BRUNO; com BRUNO foram encontradas aproximadamente mais 20 porções de crack; BRUNO confessou que estava na traficância; diante dos fatos, os dois foram conduzidos para a Delegacia de Polícia; indagado se BRUNO disse a quanto tempo traficava, respondeu que não se recordava; não foi sua equipe que abordou LUCAS, mas segundo o que ouviu, BRUNO já era alguém conhecido da guarnição; quanto a LUCAS, pelo que ouviu da Polícia Civil, não sabe há quanto tempo estava na traficância, mas foi dito que veio de São Paulo para traficar naquele local, sendo que fazia pouco tempo; só teve contato com o usuário depois que foi feita a abordagem; conversou com tal usuário e, segundo ele, comprou as drogas de LUCAS. Eis a prova oral formada.

Os réus confessaram a prática da traficância.

LUCAS assumiu que estava praticando o tráfico de drogas e alegou que carregava consigo, no dia da ocorrência, uma pochete na qual havia doze porções de maconha, quinze porções de cocaína e catorze porções de crack. Assumiu, também, que foi abordado juntamente com um usuário, a quem havia acabado de efetuar a venda de uma porção de crack. Assumiu, ainda, que possuía um rádio comunicador, pelo qual mantinha contato com BRUNO, que era o "olheiro".

Afirmou que estava traficando no local havia aproximadamente uma semana, ou alguns dias mais.

BRUNO, por sua vez, assumiu que era "olheiro" de LUCAS, ou seja, avisava o corréu caso houvesse polícia chegando. Afirmou que estava em tal atividade com LUCAS há mais de um mês e que sempre atuou nesta função com LUCAS. Afirmou, ainda, que já atuava como "olheiro" quando LUCAS chegou, assumindo que era "olheiro" havia cinco meses. Assumiu, por fim, que estava com 43 pedras de crack e que o restante das drogas foi encontrado com LUCAS, esclarecendo que além de "olheiro", também ficava com parte dos entorpecentes, atuando como "meio" que é quem ajuda o traficante a vender.

A confissão dos réus foi corroborada pela narrativa dos agentes ouvidos, que confirmaram detalhadamente a ação que culminou na prisão em flagrante dos acusados. O policial civil Cristiano narrou que a polícia recebeu informações anônimas a respeito do tráfico praticado na localidade em questão, bem como sobre a existência

de "olheiros" no local, os quais avisavam, por meio de rádios, sobre a presença da polícia. Assim, em viaturas descaracterizadas, juntamente com a guarda municipal, efetuaram diligência e dividiram-se em equipes.

Sua equipe visualizou o acusado LUCAS numa viela e, quando terceira pessoa se aproximou dele, aparentemente para efetuar uma compra de entorpecente, foi feita a abordagem.

A testemunha afirmou que LUCAS trazia consigo uma pochete, dentro da qual havia 16 porções de cocaína, além de crack e maconha, bem como R\$ 4,00 em dinheiro. O réu ainda tinha consigo um rádio HT em suas mãos. Cristiano confirmou que o réu confessou a traficância.

De teor muito semelhante, o depoimento da policial civil Marcela, que participou da diligência juntamente com a equipe do Delegado de Polícia, Dr. Hermes. A agente afirmou que durante campanha, observaram que o réu BRUNO possuía um rádio HT e se comunicava com outra pessoa a todo tempo, andando de um lugar para outro.

A testemunha narrou que ao abordarem o réu, encontraram com ele o rádio além de porções de crack embaladas de forma distinta e prontas para a venda.

Marcela confirmou que BRUNO confessou que as drogas eram destinadas ao tráfico.

Por fim, o guarda municipal Luís Henrique também participou da diligência.

Confirmou que LUCAS trazia consigo uma pochete e várias porções de cocaína, crack e maconha, embaladas separadamente para o comércio. Explicou que permaneceram observando BRUNO, que também estava com um rádio HT e que o tempo todo ele se comunicava com alguém. Ao abordarem BRUNO, encontraram com referido réu aproximadamente mais 20 porções de crack, sendo que BRUNO confessou que praticava o tráfico.

Destarte, está devidamente comprovada a prática do tráfico de entorpecentes por parte dos acusados, sendo que eles próprios confessaram a ação, confissão esta que restou corroborada pelo depoimento das testemunhas policiais.

Rememore-se que os depoimentos judiciais prestados por guardas municipais ou policiais, sejam civis ou militares, têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido eventual preconceito acerca de seus testemunhos.

Inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por guardas municipais ou policiais, sejam civis ou militares, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder

Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Inexiste, ainda, qualquer impedimento ou suspeição, no Código de Processo Penal, que faça desmerecer, em princípio, depoimentos provenientes de guardas municipais e policiais, civis ou militares, sendo inconstitucional qualquer entendimento que retire valor, a priori, dos depoimentos dos agentes da Lei, pelo simples fato de emanarem de pessoas revestidas de tal qualidade.

Neste sentido:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Por isso, os depoimentos dos agentes da Lei merecem total credibilidade e servem perfeitamente como supedâneo para prolação de sentença condenatória - ainda mais como no caso dos autos, em que corroboraram plenamente a confissão prestada pelos

acusados.

O laudo pericial acostado ao processo (fls. 110/112) atestou que as substâncias apreendidas pela polícia restaram positivas para Tetrahydrocannabinol e cocaína, substâncias de uso proscrito no Brasil.

Cumpra esclarecer que o crack é produzido a partir dos restos do refino da cocaína, que, por sua vez, é produzida a partir de uma pasta-base. O crack, portanto, não é substância autônoma, mas sim subproduto da cocaína. Logo, é certo que o laudo de exame químico-toxicológico, ao analisar o crack, atestará a presença de cocaína. Em suma, a prova oral formada, com confissão dos acusados, confirmadas em juízo tanto pelos próprios réus quanto pelas testemunhas ouvidas, a narrativa linear dos agentes policiais, a droga apreendida, ou seja, todo o flagrante em si, são circunstâncias que trazem a certeza necessária para o decreto condenatório pelo delito previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, não havendo dúvidas a respeito da ocorrência dos fatos e sua autoria, ou mesmo outras circunstâncias aptas a ensejar a absolvição dos réus.

Reconhecida a autoria, passo a dosar a pena.

Por ostentarem situações semelhantes, a dosimetria a seguir refere-se a ambos os acusados.

Na dosagem da pena devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59 do Código Penal. No entanto, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Os réus são primários e não ostentam antecedentes. Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar. Pouco se colheu a respeito da conduta social ou da personalidade dos acusados. Quanto aos motivos do crime, nada a apurar. Quanto à natureza e quantidade do produto, foram apreendidas 19 porções de maconha, 59 porções de crack e 16 porções de cocaína. Para que não se alegue bis in idem, a quantidade e variedade de entorpecentes será avaliada na terceira fase de dosimetria de pena.

Assim, com base no exposto nesta primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, diária mínima, considerando-se a ausência de informes a respeito de eventual renda auferida pelos réus. O valor total da pena de multa deverá ser atualizado nos termos do art. 49, §2º, do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria, não há a incidência de agravantes. É rigor o reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 65, incisos I (os réus não eram maiores de 21 anos à época da ocorrência) e III, alínea "d" do Código Penal (confissão). A pena, entretanto, não pode ser atenuada aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual permanece fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira e última fase da dosimetria penal, não há causas de aumento a serem consideradas. Entendo ser impossível o reconhecimento da benesse prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Apesar de os réus serem primários e não ostentarem maus antecedentes, o fato é que traficavam em conluio, de forma organizada, com uso de rádio comunicador para evitar abordagens policiais e traziam consigo considerável quantidade de três tipos de entorpecentes, dentre os quais, o crack.

O crack é um dos entorpecentes mais perigosos conhecidos, gerador dos efeitos mais nefastos em seus usuários. A alta taxa de mortalidade entre os consumidores e o absurdo poder viciante do entorpecente são motivos mais que suficientes para que seja, sua comercialização, exemplarmente repreendida (artigo 42, Lei 11.343/06). Sobre o tema, pronunciou-se Guilherme de Souza Nucci: "(...) não é demais ressaltar que a natureza e a quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias e das consequências do crime, elementos também constantes do art. 59 do Código Penal (...) A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que significa destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a

quantidade da substância ou do produto. É natural supor que quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude de sua utilização” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas 6ª ed. - São Paulo: RT 2012 v. 1 p. 287).

Ademais, o próprio réu BRUNO assumiu que estava praticando o tráfico, nas funções de “olheiro” e “meio”, juntamente com LUCAS há mais de um mês, o que demonstra que os réus faziam da atividade seu meio de sustento.

Não obstante, não há informações nos autos de que os réus eram responsáveis por preparar a cocaína que traziam consigo a partir da pasta-base. É sabido que o produto (cocaína) é refinado em laboratórios ligados, geralmente, a grandes traficantes. É o suficiente para atestar o envolvimento dos acusados com a cadeia de criminosos responsável pelo tráfico de entorpecentes e, invariavelmente, de sua dedicação a atividades criminosas de traficância.

Por fim, e não menos importante, não se pode ignorar o grande dano que vem sendo causado pelos supostos 'pequenos traficantes'.

A ilusão de que eles são figuras socialmente inofensivas não pode cegar o entendimento do julgador, a quem a Lei deu a faculdade de aplicar o benefício do parágrafo 4º, não havendo direito subjetivo do réu à sua aplicação. E não se justifica o argumento de que o crime é praticado sem violência ou grave ameaça, e de que o réu é primário e de bons antecedentes.

Primeiramente, o fato de o réu ter sido PEGO pela primeira vez, não quer dizer que ele esteja PRATICANDO o fato criminoso pela primeira vez. Outrossim, por trás de todo 'pequeno traficante', há os grandes fornecedores. A função do intitulado 'pequeno traficante' é primordial na cadeia criminosa, sendo que o fracionamento do tráfico vem sendo usado como artifício dos traficantes em geral, inclusive, como forma de terem suas condutas desclassificadas para uso próprio, diante da pequena quantidade encontrada em seu poder, fazendo com que muitos julgadores absolvam os grandes responsáveis pela entrega das drogas aos viciados: 'o traficante de porta de escola', o 'pequeno traficante', o 'traficante-viciado'.

No entanto, a conduta deles deve ser analisada com o devido rigor.

Conforme brilhante explanação de Edilson Mougenot Bonfim, Doutor em Direito Processual Penal, Professor da Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais e Escritor, “Costuma-se dizer que grande parte dos presidiários hoje - e se justifica o aumento da população carcerária também por isso -, que grande parte dos presidiários, advém do 'pequeno tráfico de drogas' e que nós deveríamos ter uma política criminal voltada ao encarceramento 'do grande traficante' - tenho visto isto com a certa recorrência de declarações de autoridades na mídia. Não sei como se faz essa distinção de 'pequeno traficante' para 'grande traficante', ao ponto do 'grande' merecer a prisão e o 'pequeno' não. Um 'grande traficante' não vai ele próprio traficar, levar 10 toneladas de cocaína ao local. Ele se vale dos 'pequenos' para a distribuição. Todo soldado que entra neste exército quer ser General, e se o Estado premiar, no primeiro dos seus delitos, de tráfico, ainda que 'pequeno', será como que um prêmio, um incentivo, para que ele busque o 'generalato', afinal de contas, o Estado estará lhe passando a mão na cabeça, como recomendam, uns tantos quantos gênios do Direito, que não conseguiram baixar, com as suas ideias, a criminalidade em local nenhum do mundo. Foi preciso que um homem quebrasse o paradigma mundial, destes que especulavam com discursos penais, e diziam que nós deveríamos tratar com blandícia aquele que cometer o 'pequeno crime', que nós deveríamos tratar com comiseração o 'pequeno delinquente'. Nós tínhamos, então, uma matriz piedosa, que dizia que o Estado não tinha legitimidade de punir aquele que cometesse um 'pequeno delito'. Um homem quebrou esse paradigma, não farei um elogio vazio (...), farei um elogio pautado naquilo que é história. Nova Iorque, antes e depois de Rodolfo Juliani. Antes, tomada por gangues, onde havia criminalidade imperando em todos os quadrantes sociais e a política de Tolerância Zero, que até um Presidente Francês, socialista, mandou seus estudiosos para trazer a 'tolérance zéro' para França, modelo que foi discutido mundialmente com este homem, que quebrou o paradigma e disse: 'Tolerância Zero desde o primeiro delito, porque nós assim temos verdadeira piedade do Homem', nós impediremos que

ele componha uma 'sinfonia criminoso musical' no futuro, porque já no primeiro delito, na primeira 'nota musical criminoso', nós o puniremos, e aí ele saberá que existe o Estado para punir aquilo que, muitas vezes, faltou autoridade paterna, faltou autoridade escolar, faltou alguma autoridade que é preciso chegar o Estado com a sua voz, com a sua força, com os seus regramentos, para fazer alguma verdade imperar. Então, o equívoco que se recita é se tratar 'pequeno criminoso', 'pequeno traficante' e 'grande traficante', e só o segundo estaria sujeito à prisão. Ora, o 'pequeno' ele anda de acordo com as suas 'pernas financeiras'. Ele não é grande, não é porque ele tem escrúpulos, é porque ele não pode. Ele trafica 100 gramas porque ele não pode traficar 10 toneladas. Se ele pudesse, ele o faria. O dolo é o mesmo. Ontologicamente, o ser criminoso e a danosidade social que isto provoca ou impacta, é a mesma. O 'grande traficante' se vale da sua rede de 'pequenos traficantes'. E se o Estado ficar com comiseração com relação ao 'pequeno', ele estará dizendo: 'podem ter mil abelhas trabalhando, que eu farei vistas grossas, desde que eu consiga pegar alguém maior'. Isto vai acontecer cada vez mais o fracionamento do tráfico. Será um incentivo e será uma antipolítica de inteligência criminal. Nós não devemos esquecer que aquele que mata um, como que é aquele que mata, e pratica o crime de homicídio, estão ambos sujeitos às penalidades de prisão, por ter praticado o homicídio. Ontologicamente, quem trafica pouco, ou quem trafica muito, pratica o mesmo crime. Se esta pauta ou esta inteligência valer para esse tipo de crime, nós também vamos começar a dizer: 'olha, matou só um, não vale a pena de prisão; estuprou só uma, não valeria a pena de prisão'. E isto é, me parece, a anti-inteligência do Direito Penal, quando nós esquecemos, neste momento, do que seja a danosidade social deste crime de tráfico de drogas e do que ele pode acarretar recebendo um verdadeiro incentivo do Estado. É verdade, nenhum de nós fica feliz em assistir à punição de um traficante. Creio que não. O homem não deve se comprazer com a dor alheia - e sempre haverá dor àquele punido -, mas, como no velho poema de Augusto dos Anjos: 'a mesma mão que bate, é a mesma mão que acaricia'. Aqueles que não respeitam os regramentos de conveniência de uma sociedade politicamente organizada, à qual chamamos de Estado, nós precisamos chamar alguma força do Estado, para restabelecimento da ordem, sob pena de nós deixarmos a justiça por conta própria, a critério de cada qual. Há um pensamento, de cunho religioso, recitado desde sempre: 'quem tem piedade dos seus lobos, perderá suas ovelhas'. Quando se trata de crime de tráfico de entorpecentes, não pense somente no 'grande traficante'. Pode ser que apenas um, o pipoqueiro da escola, viciie o seu filho. E quando seu filho estiver viciado, e o futuro dele destruído, você entenderá que o 'pequeno' também pode ser um 'grande traficante', que levou o que de mais precioso você tem na vida, a sua descendência, a próxima geração" (fonte: youtu.be/1Pb_2RG_gcY).

Assim, não incidem causas de diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva dos acusados em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

O regime inicial para cumprimento de pena será o fechado.

O tráfico de entorpecentes é das atividades mais danosas ante o seio social hodierno. Sua prática atinge diretamente direitos e garantias fundamentais das pessoas, além de fomentar outros tipos de atividades ilícitas. Causa, ainda, direta e indiretamente, considerável mobilização estatal, atingindo, por consequência, o erário público, que tem de arcar com as custas de policiamento ostensivo, seja preventivo ou repressivo, campanhas de conscientização - sobre o óbvio, diga-se -, tratamento de saúde aos adeptos do uso contumaz, dentre outras inúmeras situações relacionadas, as quais requerem pronta ação do Estado. Isto, entretanto, custa dinheiro e onera o contribuinte.

Seria um contrassenso o mesmo Estado que luta para combater tão nefasta prática - a tão altos custos - permitir que seu principal responsável retorne à liberdade sem experimentar a necessária punição e, principalmente, sem que de seu ato se arrependa, sobre ele reflita e o corrija, podendo criar, em última análise, a aplicação de regime mais brando, verdadeira sensação de impunidade, capaz, inclusive, de ensinar ao condenado mais um motivo para que torne à rentável prática.

Nem se diga haver o pequeno traficante, sobre quem recairia todo o peso da mão

Estatal, e o grande traficante, que se ocultaria na hierarquia da coalizão narcotraficante, como tentativa de justificar atos injustificáveis. A Lei coíbe o tráfico e este existe por duas razões: porque alguém consome o produto e, principalmente, porque alguém o vende – eis a figura daquele que trafica, independentemente de sua posição hierárquica.

A ação do indivíduo encarregado de disseminar a substância entorpecente – geralmente identificado como o “pequeno traficante” – deve ser entendida como parte integrante e crucial do conjunto responsável pela narcotraficância: é ele que, por meio de sua ação, viabiliza o comércio “varejista” das drogas, fomentando o consumo e a própria continuidade da produção de entorpecentes, consubstanciando, sua atividade, não só o meio de sustento próprio, mas de toda a cadeia criminoso ligada ao narcotráfico – prática delitativa que domina a maior parte dos debates sobre segurança pública e que consiste, em verdade, no cerne financeiro das atividades criminosas em geral.

É do espírito da Lei combater o tráfico ilícito de entorpecentes, seja ele praticado pelo iniciante – a quem é conferido algum tipo de benefício, conforme se observa do parágrafo 4º do artigo 33, Lei 11.343/06 – pelo gerente de “boca” ou por associados a organizações criminosas – pessoas a quem a Lei trata de maneira especial e mais severa.

O fato é que o tráfico, independentemente do tipo de atuação de seu praticante, merece reprimenda exemplar.

Sobre todo o tema até então debatido, uma brilhante manifestação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“(…) Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de 27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e a recente decisão da Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo entendimento. Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de direitos” constantes dos artigos 33, § 4º e 44 da Lei Antidrogas. Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia, não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos. Na decisão é ressaltada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição. Tal como veiculado de forma contínua nos diários de grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades, inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação. Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião; o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal. Evidentemente o grande traficante, o responsável pela distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte, disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de necessidades básicas. Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto, e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. O número expressivo de pessoas que poderiam ser servidas com as drogas, bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena por quaisquer das medidas alternativas. Portanto, acolho a pretensão do representante do Ministério Público e fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, tendo em vista que se trata do regime compatível com a conduta do acusado. Cumpre ressaltar ainda que as circunstâncias dos autos, a meu sentir, data máxima vênia, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se tratava de

pequenos traficantes, mesmo porque esta simplória qualificação é permeada por um revés de complexidade. Qual a equação para se distinguir o grande traficante do pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão? A constância da atividade do comércio ilegal? Cabe aqui outra indagação: não parece pouco provável que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante? A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a causa de tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os préstimos do pequeno traficante. Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator, beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria das vezes, voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas. E a consequência desta fartura financeira é previsível, ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta parte tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios espúrios para a sua sobrevivência. Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano. Devo reconhecer que tenho sido voto vencido junto a meus pares, a cujos posicionamentos me curvo com a humildade esperada, e por isso mesmo, eventualmente, sou reconhecido como extremamente rigoroso, entretanto, não o faço como castigo, o que seria de todo despropositado e bem acarretaria o desvirtuamento da finalidade da pena. É imperativo ressaltar também que não tenho a menor intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes - como Relator dos autos aos meus cuidados - o redutor previsto na Lei nº 11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria visualizar a figura do pequeno traficante. (...)” (APL TJ-SP 0027320-18.2012.8.26.0224; Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal Extraordinária; Publicação: 18/01/2017; Julgamento: 14 de Dezembro de 2016; Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro).

Salutar a fundamentação, que reduz a termo o espírito buscado pela construção normativa do Legislador. É razão mais que suficiente para que se entenda que o praticante do tráfico de drogas deve permanecer afastado do convívio em sociedade. Ficam vedados, ainda, pelas mesmas razões, quaisquer outros benefícios, incluindo-se a substituição da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pelas razões acima apontadas, tudo a indicar não ser referida conversão medida adequada e suficiente ao caso concreto.

Assim é que se decide.

Centrado nestes fundamentos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno os réus como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 às penas de:

- LUCAS VASCONCELOS MAGRI: 05 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 500 dias-multa, diária mínima, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, §2º, do Código Penal; e

- BRUNO DE SOUZA: 05 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 500 dias-multa, diária mínima, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do

art. 49, §2º, do Código Penal.

O réu LUCAS está preso e assim deverá permanecer, já que foi preso em flagrante, permaneceu recolhido por todo o processo e não seria razoável, agora que foi condenado, ser colocado em liberdade, ainda mais diante do regime imposto pela Lei e do fato de ter praticado conduta de extrema gravidade, que deve ser exemplarmente punida. Ademais, não há segurança ao juízo de que o réu, uma vez em liberdade, não acabe voltando a praticar o delito que culminou com sua prisão, seja para saldar eventual dívida que ostente com o tráfico pela apreensão da grande quantidade de entorpecentes, seja para garantir seu próprio sustento. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra.

O réu BRUNO respondeu o processo em liberdade e, não tendo havido alteração da situação fática que lhe franqueou tal direito, poderá apresentar eventual recurso sem se recolherem ao cárcere.

Transitada esta sentença em julgado, comunique-se a presente condenação à Justiça Eleitoral em atenção o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Decreto a perda, em favor do FUNAD, do valor em dinheiro apreendido nos autos, uma vez não comprovada a sua origem lícita. Após o trânsito em julgado, oficie-se para levantamento.

Condene os réus ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada eventual gratuidade da Justiça.

P.I. e C.

Atibaia, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA